

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2020-1-1]일부인용재결 및 감경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

《【문제1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A시 소재의 3층 건물의 1층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3월의 영업정지처분을 1월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲이 제기하는 취소소송의 대상적격, 피고적격, 제소기간에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 일부인용재결 및 감경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 3월의 영업정지처분에 대하여 행정심판을 청구하였고, 일부인용재결에 따라 1월의 영업정지처분으로 변경되었으나 이에 불복하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <甲이 제기하는 취소소송에서 소의 대상, 피고 및 제소기간이 적법하게 갖추어졌는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하는 취소소송의 대상적격, 피고적격, 제소기간에 대하여 논한다.

II. 감경 변경재결 및 후속 변경처분이 있는 경우의 법리

1. 대상적격의 판단 기준

(1) 원처분주의의 원칙

- 행정소송법 제19조 본문에 따라 취소소송은 원칙적으로 행정청의 처분을 대상으로 한다. 행정심판을 거친 경우라 하더라도 재결 자체에 고유한 하자가 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 감경 변경처분의 경우

- 대법원은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액되거나 감경된 경우, 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 독립된 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가진다고 판시한다. 따라서 취소소송의 대상은 감경 변경처분이 아니라 감경되고 남은 내용의 당초처분이 된다.

2. 피고적격의 판단 기준

(1) 처분청 피고의 원칙

- 행정소송법 제13조 제1항에 따라 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분을 행한 행정청(처분청)을 피고로 삼아야 한다.

(2) 피고 지정의 법리

- 일부인용재결에 따라 당초처분의 효력이 일부 감경된 경우라 하더라도, 소송의 대상이 원처분(감경되고 남은 당초처분)인 이상, 피고는 재결을 내린 행정심판위원회가 아니라 원래의 원처분을 행한 처분청이 되어야 한다.

3. 제소기간의 기산점과 계산

(1) 행정심판을 거친 경우의 특칙

- 행정소송법 제20조 제1항 단서에 의하면 행정심판을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우, 제소기간은 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내로 규정되어 있다. 이는 불변기간에 해당한다.

(2) 기간 계산의 원칙

- 민법 제157조 및 행정소송법 제8조 제2항에 따라 기간을 계산할 때는 초일을 산입하지 아니한다(초일불산입 원칙). 따라서 재결서 정본을 송달받은 다음 날부터 기산하여 90일이 되는 날을 만료일로 산정한다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- 사안에서 A시장 乙이 행한 2020. 3. 17.자 후속 변경처분은 당초의 3월 영업정지처분을 1월로 감경한 것에 불과하다. 따라서 甲이 제기해야 할 취소소송의 대상은 2020. 3. 17.자 변경처분이 아니라 1월의 영업정지처분으로 변경되고 남은 당초 2019. 12. 26.자 영업정지처분이 되어야 한다. 그러므로 변경처분 자체를 소송의 대상으로 삼고자 하는 甲의 계획은 대상적격을 오지정한 것으로서 부적법하다.

2. 피고적격의 충족 여부

- 취소소송의 대상이 1월로 변경되고 남은 당초의 영업정지처분이므로, 피고는 해당 원처분을 행한 행정청인 A시장 乙이 되어야 한다. 만약 甲이 행정심판을 거쳤다는 이유로 재결청인 행정심판위원회를 피고로 지정하여 소를 제기한다면 피고적격을 결여한 것으로서 부적법하다. 다만, 이는 법원의 피고경정(행정소송법 제14조) 절차를 통해 구제받을 여지가 있다.

3. 제소기간의 준수 여부

(1) 기산일의 확정

- 甲은 2020. 3. 10.에 행정심판 재결서 정본을 송달받았다. 초일불산입 원칙에 따라 제소기간의 기산일은 다음 날인 2020. 3. 11.이 된다.

(2) 90일 만료일 산정

- 2020. 3. 11.부터 90일이 되는 날을 계산하면 다음과 같다. 3월은 총 31일까지 있으므로 기산일인 11일부터 31일까지 남은 일수는 21일이다. 4월은 30일, 5월은 31일이므로 여기까지의 누적 일수는 82일(21+30+31)이다. 따라서 90일이 만료되는 날은 6월의 8번째 날인 2020. 6. 8.(월)이 된다.

(3) 준수 여부 판단

- 甲은 2020. 6. 15.에 취소소송을 제기하고자 한다. 이는 적법한 제소기간의 만료일인 2020. 6. 8.을 이미 도과한 시점이므로, 甲의 소송은 제소기간을 준수하지 못하여 부적법하다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 제기하고자 하는 취소소송은 소송요건을 결여하여 부적법하므로 법원에 의해 각하되어야 한다. 첫째, 소송의 대상은 감경되고 남은 당초처분이어야 하므로 후속 변경처분을 대상으로 삼은 것은 대상적격을 결여한 것이다. 둘째, 피고는 행정심판위원회가 아닌 원처분청인 A시장 乙이 되어야 한다. 셋째, 가장 결정적으로 재결서正本 송달일인 2020. 3. 10.로부터 90일이 되는 날은 2020. 6. 8.이므로, 2020. 6. 15.에 제기하는 소송은 불변기간인 제소기간을 경과하여 구제받을 수 없는 부적법한 소에 해당한다.